

1503581-27.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), as circunstâncias e o local da prisão, conhecido como ponto de tráfico, assim como o depoimento incriminador dos policiais militares, tudo a apontar o réu como sendo pessoa envolvida no tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503581-27.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503581-27.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2317643/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21533806 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2915/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2317643 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2915/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID DE LIMA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

DAVID DE LIMA SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, inciso III, ambos Lei n.º 11.343/06.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Doutor Mario Camargo Aranha, nº 1, Jardim São Francisco, nas proximidades de um recinto de recreação esportiva, na cidade e comarca de Limeira, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 140 flaconetes contendo cocaína, pesando no total 50,87 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o réu encontrava-se na via pública com entorpecentes, para fins de tráfico.

Policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram DAVID em um local conhecido como ponto de venda de drogas e resolveram abordá-lo. Entretanto, ao notar a aproximação da viatura, o acusado pulou o alambrado de um campo de futebol e dispensou uma sacola. Na sequência, ele saiu correndo, porém foi detido em seguida.

No interior da sacola supracitada foram localizadas 137 porções de cocaína. Em busca pessoal no réu, foram encontradas outras 03 porções de cocaína semelhantes àquelas já apreendidas e R\$ 0,90.

O crime foi cometido em uma área de recreação, onde ocorria um jogo de futebol no momento da abordagem e crianças brincavam no parque ali existente.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 106/107).

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022 (fls. 108/109).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

O Ministério Público e a Defensoria Pública ofereceram alegações finais (mídia e fls. 129/141).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 26/27), auto de exibição e apreensão (fls. 28), laudo de constatação com resultado positivo para cocaína (fls. 35/37 e fls. 122/124), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em Juízo, o acusado disse que tem 31 anos. É amasiado. Trabalhava como ajudante de pintura. Havia saído da sua casa, iria comprar cigarros numa mercearia. Tinha dinheiro em seu poder. No que foi passar no local que é um ponto de tráfico, vinham três motocicletas da polícia. Tinha processo de pensão alimentícia, fugiu da abordagem por causa disso. Atravessou o campo de futebol e foi abordado na mata. Não dispensou qualquer sacola. Não tem como dispensar as porções de cocaína na fuga. Não tinha qualquer porção em seu poder. Mora no bairro Abílio Pedro, é ali perto. Não conhecia os policiais. Ocorria um jogo de futebol no campo. Tem antecedentes criminais por roubo, estava em livramento condicional (mídia).

Sua versão não convence.

Vejamos o teor da prova oral.

O policial militar Wender da Silva Oliveira disse que efetuava patrulhamento pelo local dos fatos, em local conhecido pela vasta venda de drogas, quando visualizaram o acusado caminhando na via. Percebendo a aproximação da viatura, o réu de imediato saltou sobre o alambrado de acesso ao campo de futebol, atirando ao solo uma sacola

plástica. O imputado correu para uma área verde. Verificaram que a sacola dispensada continha 137 invólucros contendo cocaína. Em busca pessoal realizada no suspeito, localizaram outros três invólucros plásticos contendo cocaína e R\$0,90 em dinheiro. Já conhecia o acusado de abordagens anteriores. O local é um campo de futebol e lá treinavam crianças, há uma praça de recreação. Indagado, ele negou os fatos e a dispensa na fuga (mídia).

O policial militar Julio Cesar Gagliardi Fischer contou que efetuavam patrulhamento rotineiro pela Rua Doutor Mário Camargo Aranha, e visualizaram o acusado pelo local dos fatos caminhando pela via. Considerando que o local é conhecido como ponto de comércio ilícito de drogas, resolveram verificar, contudo, percebendo a aproximação da viatura, o denunciado saltou sobre o alambrado de acesso ao campo de futebol, atravessou o campo e saiu do outro lado onde tem uma mata, atirando ao solo uma sacola plástica e continuando a correr. Ele pegou a sacola que o réu jogou ao solo, constatando que em seu interior havia 137 invólucros com cocaína. Em busca pessoal no suspeito, encontraram três invólucros plásticos semelhantes aos demais encontrados, também contendo cocaína, e R\$0,90 em dinheiro. O local em que o réu foi avistado inicialmente é uma área de recreação do bairro e, no momento da abordagem, ocorria um jogo de futebol entre crianças, existem equipamentos de recreação para idosos. Indagado, ele negou os fatos e disse que a droga encontrada era de seu uso, ele negou qualquer dispensa. Já conhecia o réu de abordagens anteriores (mídia).

No que toca aos depoimentos de policiais, é de rigor consignar que aqueles não podem ser valorados de forma depreciativa, mormente se de acordo com os demais elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, “a priori”, valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais “lato sensu”. Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pois bem.

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais militares faziam patrulhamento quando visualizaram o acusado em um local conhecido como ponto de venda de drogas. Com a aproximação da viatura, DAVID pulou o alambrado de um campo de futebol, onde ocorria recreação de crianças, dispensando uma sacola na fuga.

Posteriormente, na área verde ele foi detido pelos agentes públicos. Na sacola dispensada pelo acusado, foram localizadas 137 porções de cocaína. Em revista pessoal, mais 03 porções de cocaína semelhantes às apreendidas e dinheiro foram encontrados.

Assim, respeitado o entendimento da combativa Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), as circunstâncias e o local da prisão, conhecido como ponto de tráfico, assim como o depoimento incriminador dos policiais militares, tudo a apontar o réu como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

E não há que se falar em desclassificação do delito imputado para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (140 flaconetes com cocaína), assim como as circunstâncias da prisão, com depoimento incriminador dos policiais militares

quanto ao crime de tráfico de drogas.

Em conformidade com os ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

A respeito do assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim já decidiu:

"Tráfico de entorpecentes – Dolo de traficar – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância. (...)" (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos agentes públicos para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Por outro lado, não foram arroladas testemunhas de Defesa que corroborassem a versão do imputado de não ter qualquer envolvimento com a traficância ilícita, devendo prevalecer o relato dos policiais militares que efetuaram a abordagem e o prenderam em flagrante delito.

E não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é

condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Note-se que o acusado não tinha trabalho lícito e formal ao tempo dos fatos que lhe propiciasse a aquisição de toda aquela quantidade de entorpecente.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A natureza e quantidade de drogas apreendidas no caso em tela não justificam a exasperação da pena-base, pois não se trata de quantidade elevada.

O réu é reincidente (F.A de fls. 47/48 – autos nº 7000640-40.2010.8.26.0451). Desta forma, elevo a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Na terceira fase, não reconheço a existência de bis in idem, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, eis que o acusado é reincidente, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO DOS ARTS. 59 E 33, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 2. Tratando-se de Paciente reincidente, não faz jus à aplicação da minorante inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, nem tampouco resta caracterizado bis in idem diante da utilização da

reincidência como agravante genérica e como fundamento para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes (...) 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (STJ, HC 231.511/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada". (STJ, HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 148.575/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, uma vez que o crime foi praticado nas imediações de uma área de recreação, onde ocorria um jogo de futebol e perto de crianças que brincavam naquele local, de modo que elevo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Pouco importa se o réu visava ou não atingir tais crianças ou se ele efetivamente comercializava entorpecentes diretamente com tais pessoas, bastando que o fato criminoso ocorra nas proximidades dos locais descritos no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas, na esteira da jurisprudência abaixo:

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A causa de aumento de pena previsto no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas não se limita apenas àquelas hipóteses em que o agente, efetivamente, ofereça a sua mercadoria ilícita às pessoas que estejam em sedes de entidades sociais, culturais, recreativas ou esportivas, bastando que se atue em suas proximidades, tudo como forma de diminuir a possibilidade de oferta de drogas nos lugares elencados pela lei. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 682.665/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016).

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. DIMINUIÇÃO DA PENA. BENEFÍCIO NEGADO. INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO À

ATIVIDADE CRIMINOSA. 2. CRIME COMETIDO PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. (...). 2. A constatação de que o tráfico de drogas era praticado nas imediações de estabelecimento de ensino torna dispensável a comprovação de que o paciente comercializava entorpecentes diretamente com os alunos da escola. 3. Ordem denegada". (STJ, HC 121.793/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 31/08/2011).

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO PRÓXIMO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROFUNDO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO-CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. A constatação de que o tráfico de drogas era praticado nas imediações de estabelecimento de ensino torna dispensável a comprovação de que o paciente comercializava entorpecentes com os alunos da escola. (...) 3. Ordem denegada". (STJ, HC 154.915/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 15/03/2010).

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, sobretudo pela reincidência, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006.

Não basta a primariedade para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, a personalidade do agente e a conduta social do agente.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar DAVID DE LIMA SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, inciso III, ambos Lei n.º 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante este processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências do tráfico de drogas para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar o comércio espúrio de drogas, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é reincidente.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Após o trânsito em julgado, o nome do acusado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

P.R.I.

Limeira, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA